

1502799-51.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502799-51.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502799-51.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231887/2021 - DEL.POL.CUBATÃO, 19851300 - DEL.POL.CUBATÃO, 689/21/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2231887 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDREY ALVES RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHES FAVERO

I - RELATÓRIO

ANDREY ALVES RODRIGUES foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 11h25, na Rua Seis, defronte ao nº 200, Cubatão, ANDREY ALVES RODRIGUES, qualificado a fls. 03, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, cocaína, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 05/06, auto de constatação preliminar de fls. 07 e laudo definitivo das drogas de fls. 64/66. Segundo o apurado, policiais civis,

durante atuação de campo, em uma viatura descaracterizada, realizaram uma breve campanha, no local dos fatos, e perceberam que vários usuários de droga se dirigiam ao beco e, em frente ao numeral 200, avistaram um indivíduo sentado, sendo possível notar que recebia algo e, na sequência, entregava alguma coisa em troca. Em dado momento, se aproximaram e abordaram referido indivíduo, ora denunciado. Em revista pessoal, lograram êxito em localizar, no bolso de sua jaqueta, uma sacola pequena, de cor preta, contendo, em seu interior, 20 (vinte) pinos contendo cocaína (peso líquido - 6,5g), R\$100,00, em espécie, além de uma folha de caderno de anotações. A razoável quantidade de entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, os testemunhos dos policiais, demonstram que o denunciado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2021 (fls. 75/79).

O acusado foi citado (fls. 110) e apresentou defesa prévia.

Juntada sua folha de antecedentes em fls. 26/27.

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez (fls. 130-131), requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Inicialmente, gizo que incabível a alegação de que o flagrante foi preparado.

O flagrante provocado ou preparado é aquele em que ocorre a indução ou instigação para que agente cometa o crime, com o fito de se efetuar a prisão. Como ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA, o flagrante preparado, também chamado de provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador, "ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consuma". (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.035.) A atuação dos policiais, como se vê, não se amolda à figura do flagrante preparado, mas sim ao que na doutrina convencionou-se chamar de flagrante esperado, em que, "valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante" (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.036).

Assim, dos fatos narrados restou evidente que não houve qualquer tipo de preparação dos agentes policiais para que o Réu cometesse o crime. Não houve qualquer provocação escrupulosamente engengrada, a ensejar o nascedouro ou a gênese da intenção ou volição do Réu para a prática ou consecução da conduta. Ao contrário, os agentes policiais estavam em patrulhamento e perceberam a ocorrência.

Em verdade, o que poderia ter no caso em tela, é um verdadeiro flagrante diferido (ação controlada), conforme previsão contida no art. 53, inc. II da Lei 11.343/06 e no art. 3º, inc. III da Lei nº 12.850/2013. Afinal, esta modalidade de obtenção probatória consiste "em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações" (art. 8º da Lei 12.850/2013).

Logo, o crime - que é permanente - já estava sendo praticado antes mesmo da chegada

dos policiais. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça que se aplica perfeitamente à espécie:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR FLAGRANTE PREPARADO COM FLAGRANTE ESPERADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. 1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado - em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração. 2. A 'campana' realizada pelos policiais a espera dos fatos não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente criminoso tão-somente a espera da prática da infração penal. (...) 6. Writ denegado (HC 40.436/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 02/05/2006, p. 343).

Ademais, não há quaisquer nulidades quanto a prisão em flagrante, posto que a mesma já fora analisada na audiência de custódia, sendo inclusive homologada. Ultrapassada essa questão prévia, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP - passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 "representa uma nova política na seara das drogas" (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: "todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados" (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., RESp.

1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição/apreensão (fls. 05/06), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 07), termo de depoimento (fls. 08/09), relatório final (fls. 62/63), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está

implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciará.

Vejam os:

Em solo policial, o condutor e testemunha HEBER VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA disse que “na manhã de hoje, participava de uma atuação de campo de Polícia Judiciária juntamente com o policial civil Wandré, e do interior de uma viatura descaracterizada, iniciaram uma breve campanha nas proximidades do local os fatos, onde funciona uma “biqueira”, ou seja, um ponto de venda de drogas. Durante a observação notaram que usuários de droga se dirigiam para o beco e, em frente ao numeral 200 avistaram o indiciado sentado, sendo possível notar que o mesmo recebia algo e na sequência entregava alguma coisa em troca. Diante da movimentação típica do comércio de entorpecentes, desembarcaram da viatura e resolveram abordar o indiciado, identificando-se como policiais. Durante revista pessoal, no bolso de sua jaqueta, foi localizada uma sacola pequena de cor preta contendo em seu interior 20 (vinte) pinos contendo pó branco aparentando cocaína, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) e uma folha de caderno contendo anotações manuscritas. Diante dos fatos deram voz de prisão e o indiciado foi conduzido até esta unidade policial, tendo a Autoridade Policial ratificado a voz de prisão procedendo-se ao registro do Auto de Prisão em Flagrante Delito, sendo que o preso será encaminhado a cadeia anexa ao 5 Distrito Policial de Santos onde permanecerá a disposição da Justiça” (fls. 08). Em Juízo, disse que estava realizando campanha no local, com seu parceiro, em viatura descaracterizada. Sabiam que na localidade funcionava um ponto de tráfico de drogas. No dia viram várias pessoas se movimentando e indo em direção ao numeral em que preso o Réu. Após alguns minutos verificando a movimentação, realizaram a abordagem e, com o Réu, havia droga e dinheiro. Foi a primeira vez que abordaram o Réu. A droga estava no interior do bolso da jaqueta do Réu, dentro de uma sacola. Havia cocaína embalada como de costume para mercancia. A quantia de dinheiro era em espécie, em notas miúdas. Não se recorda se houve apreensão de caderno com anotações do tráfico. Informalmente o Réu disse que residia em outro bairro e estava na localidade para comercializar drogas. Não há dúvidas sobre a pessoa do Réu. No momento da abordagem o Réu estava sozinho. Visualizaram pessoas comprando as drogas com o Réu. Não detiveram nenhuma pessoa que realizou a compra de drogas com o Réu.

Em solo policial, a testemunha WANDRE DOS SANTOS REIS disse que “na manhã de hoje, participava de uma atuação de campo de Polícia Judiciária juntamente com o policial civil Heber, e do interior de uma viatura descaracterizada, iniciaram uma breve campanha nas proximidades do local os fatos, onde funciona uma “biqueira”, ou seja, um ponto de venda de drogas. Durante a observação notaram que usuários de droga se dirigiam para o beco e, em frente ao numeral 200 avistaram o indiciado sentado, sendo possível notar que o mesmo recebia algo e na sequência entregava alguma coisa em troca. Diante da movimentação típica do comércio de entorpecentes, desembarcaram da viatura e resolveram abordar o indiciado, identificando-se como policiais. Durante revista pessoal, no bolso de sua jaqueta, foi localizada uma sacola pequena de cor preta contendo em seu interior 20 (vinte) pinos contendo pó branco aparentando cocaína, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) e uma folha de caderno contendo anotações manuscritas. Diante dos fatos deram voz de prisão e o indiciado foi conduzido até esta unidade policial, tendo a Autoridade Policial ratificado a voz de prisão procedendo-se ao registro do Auto de Prisão em Flagrante Delito, sendo que o preso será encaminhado a cadeia anexa ao 5 Distrito Policial de Santos onde permanecerá a disposição da Justiça” (fls. 09).

Em Juízo, reiterou a versão apresentada em solo policial e o quanto informado por seu colega, agora sob o manto do contraditório.

Em solo policial, o acusado ANDREY ALVES RODRIGUES disse que manifesta o desejo de somente pronunciar-se em Juízo (fls. 12).

Interrogado em Juízo, disse que quando foi abordado estava na frente da casa de uma usuária de drogas. Estava utilizando drogas com uma mulher dentro da casa desta

mulher. No dia, em torno das 9hrs da manhã, os policiais invadiram a residência da mulher e o levaram até a delegacia. Não levaram a mulher. Não estava vendendo drogas. As pessoas iam para a casa da mulher e usavam drogas lá. É usuário de cocaína. Cada pino de cocaína possui em torno de 1g e custa R\$ 2,00. Nunca havia visto os policiais. A casa da mulher possui portas. Os policiais arrombaram a entrada. Os pinos de cocaína eram seus. Quem comprou a droga foi a mulher da casa. Não utilizou a droga em sua casa porque morava com seu pai.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia, pois a versão apresentada pelo Réu não encontra eco no manancial probatório, quedando-se isolada.

Ademais, a comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perlustra que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, “a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98).

A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada

foi levantado neste sentido -, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); "...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)." (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos.

Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que o acusado, de forma deliberada, guardava e tinha em depósito drogas - verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 -, em razoável quantidade, pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. - HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprе ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar - que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de "guardar" é apenas umas das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, o acusado foi abordado em razão de uma investigação policial já instaurada há meses.

Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas ou negativa de autora do acusado em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

Adianto que, no caso em análise, é inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque o objetivo do aludido dispositivo de lei é privilegiar a figura comumente denominada por pequeno traficante ou traficante eventual, que pouco se dedica ao comércio espúrio e, quando o faz, realiza em pequena quantidade de drogas.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelo Réu. De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria penal, encontra-se presente a agravante da reincidência (fls. 24). Agravado, assim, a reprimenda em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Ademais, na terceira fase, não há como se aplicar a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.346/06, tendo em vista a reincidência do Réu. Ademais, não comprovou ocupação lícita.

Assim, estabeleço a pena final do réu em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Diante da reincidência, do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime semiaberto (artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a" do Código Penal), notadamente pela reincidência.

O equipamento prisional inicial é o semiaberto, considerando o quantum de pena fixado, na medida em que, inexistente variedade e quantidade exacerbada de drogas apreendidas, além das circunstâncias elencadas no art. 59 serem positivas e o numerário de reprimenda compatível com o regime intermediário, forte na aplicação do art. 33, § 2º, "b", sendo ele, para o caso em espécie, o mais adequado frente aos propósitos de repressão, retribuição, ressocialização que, como visto, devem ser observados, de forma que, por mais que a gravidade do delito seja por deveras considerada, tal ponderação já foi fixada pela legislação ao delimitar os parâmetros da pena, não podendo agora a opinião do julgador se firmar sobre esse pilar para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas nº 718 e 719 do STF).

Deve-se observar a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal dispõe: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". A ementa do acórdão que resolveu o Recurso Extraordinário 641.320, na parcela que interessa ao presente caso, tem o seguinte teor:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.5.16).

Ainda em virtude do quantum da pena corporal aplicada, o réu não faz jus à substituição da pena carcerária por restritiva de direitos (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI - PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 14/15 e 86) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VII - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 387, § 2º DO CPP

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais. O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2º, do CP estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, de pois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que o réu está provisoriamente

preso e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

VIII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ANDREY ALVES RODRIGUES, qualificado a fls. 03, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, mantenho a prisão preventiva do Réu e indefiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. A manutenção da prisão preventiva do réu se impõe pelo fato de ter permanecido preso durante o curso do processo e ser reincidente. Além disso, não se verifica qualquer alteração no cenário levado em consideração no momento da decretação da prisão preventiva, de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, reforçados pelo título condenatório.

Saliento que o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente, precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014. Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública.

Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, pois traficava cocaína, droga de nocividade conhecida.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e

do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

Tratando-se de dinheiro e bens apreendido em decorrência de Tráfico de drogas, DECRETO O PERDIMENTO dos mesmos em favor da UNIÃO (art. 91 do CP, art. 63, § 1º da Lei 11.343/2006 e Provimento 20/2006-CGJ), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito” (tema 647).

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila “acompanhamento de preventiva decretada”, para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Após o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);

b) intimem-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);

c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);

d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;

e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.

f) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se caso.

g) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e a Secretária Nacional Antidrogas, para providências cabíveis, se caso.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Publique-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Cubatão, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA